

1501631-41.2020.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HEBER GUALBERTO MENDONCA

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... responde a outro processo-crime por tráfico (fls. 213/214).

A Defesa do réu, postulou a absolvição do réu. Subsidiariamente, pugnou pela redução máxima no artigo 33, parágrafo 4º, da LAD, bem como regime aberto (fls. 214/215).

II - Da Fundamentação

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou plenamente comprovada pelo:
i) boletim de ocorrência (fls. ...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

4ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501631-41.2020.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501631-41.2020.8.26.0603

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HIGOR GABRIEL HERRERO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HEBER GUALBERTO MENDONCA

I - Do Relatório

HIGOR GABRIEL HERRERO, qualificado às fls. 5, foi denunciado e processado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, em tese, no 13 de novembro de 2020, por volta das 18h50min, na Rua Gonçalves Lêdo, nº 923, Bairro Jardim Paula Pereira, nesta cidade e Comarca de Penápolis, trazia consigo, para posterior entrega a consumo de terceiros, 03 (três) invólucros contendo maconha, com peso líquido de 132,05g (cento e trinta e duas gramas e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta na denúncia que o denunciado resolveu praticar o crime de tráfico de drogas nesta cidade. Para tanto, as drogas acima foram adquiridas de fornecedor não identificado, mantidas em poder do denunciado e, após, comercializadas ao consumo de terceiros.

É dos autos que, naquele dia, policiais militares efetuavam patrulhamento nas proximidades do local dos fatos, com informações pretéritas de que o investigado praticava a narcotraficância naquela região.

Nessas circunstâncias, os policiais avistaram HIGOR, sendo que ele, ao verificar a aproximação das motocicletas da Rocam, apresentou nervosismo e mudou, repentinamente, sua direção, sendo que tentou entrar em um imóvel desabitado.

Diante do ocorrido, HIGOR foi abordado. Em revista pessoal, os policiais localizaram com o denunciado, debaixo de suas vestes, 03 (três) pedaços de maconha e uma balança dentro de uma sacola. Em sua posse, foi encontrado, também, um celular, marca Samsung, e a quantia de R\$10,00 (dez reais).

As drogas, o dinheiro, a balança e o celular foram apreendidos. As substâncias foram submetidas a exame pericial de constatação definitiva e apurou-se que se tratava de TETRAHIDROCANNABINOL (THC) -maconha (fls. 103/105).

O celular foi submetido a perícia técnica, não tendo sido possível acessar o seu conteúdo, devido à proteção por senha (fls. 106/111).

Citado/notificado (fl. 163), o réu apresentou defesa preliminar (fls. 89).

A denúncia foi recebida no dia 6.12.2021 (fls. 164/169).

Durante a instrução, ouviu-se 1 (uma) testemunha comum (fl. 217), sendo o réu interrogado ao final (fl. 216).

Em Memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, sendo contra a aplicação do artigo 33, parágrafo 4º, da LAD, dado que responde a outro processo-crime por tráfico (fls. 213/214).

A Defesa do réu, postulou a absolvição do réu. Subsidiariamente, pugnou pela redução máxima no artigo 33, parágrafo 4º, da LAD, bem como regime aberto (fls. 214/215).

II – Da Fundamentação

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou plenamente comprovada pelo: i) boletim de ocorrência (fls. 7/9); iii) auto de exibição e apreensão (fls. 24/25); iii) laudo toxicológico (fls. 103/105); iv) laudo pericial na balança digital (fls. 112/117).

A autoria também é certa, conforme se depreende da prova oral colhida.

A Testemunha/CPM Igor José de Oliveira disse que estavam de motocicleta e já tinham informações dos moradores, da escola e do cemitério (próximo à casa) sobre o envolvimento dele com droga, conhecido como “Priscilinha”. No dia, em frente a um imóvel vazio, viram-no, pelo que tentou entrar na casa. Encontraram 3 tabletes de maconha com ele (na cintura) e junto com uma balança de precisão), dizendo ser para uso. Com ele havia ainda um celular e R\$ 10,00. A casa dele não é aquela onde foi encontrado, sendo que ele usava o imóvel para guardar a droga. Após a ocorrência, o réu foi preso pelo mesmo crime e ainda há informações de que trafica.

Em seu interrogatório, HIGOR GABRIEL HERRERO disse que a maconha era sua e que era para seu uso. Nega que estivesse andando com sacola de maconha na rua. Ele tinha mudado para outro endereço (diferente da denúncia) uns 2 dias antes e tinha ido lá para pegar um cigarro de maconha, quando foi abordado, pelo que o levou até à droga. Ele disse ao PM que morou lá até dias atrás e que ainda tinha mais maconha

dentro do tal imóvel e que era para seu consumo. Diz ser vítima de perseguição de ambos os policiais, que sempre o abordam. Nega que faça tráfico de drogas. Tem um filho pequeno para criar. Na época dos fatos, trabalhava como pintor, ganhando R\$ 350,00 por semana. Tinha uma balancinha de precisão dentro do tal imóvel vazio para não ser ludibriado pelos traficantes. A droga que estava na casa duraria de 1 semana a 1 semana e meia. Gasta, por mês, uns R\$ 400,00 para comprar droga. Sua mulher também faz "bicos" como faxineira e cobra R\$ 100,00. Não vende droga para poder comprar mais.

Pois bem.

O conjunto probatório é robusto e conclusivo.

O PM ouvido confirmou que os 3 tabletes de maconha estavam com o réu, juntamente com a balança de precisão, além de um celular e R\$ 10,00, sendo que usava o imóvel vazio para guardar a droga, acrescentando haver notícia, ainda, da traficância pelo réu.

Com efeito, o testemunho de policiais reveste-se de idoneidade e credibilidade suficientes a embasar, juntamente com os demais elementos de prova, o decreto condenatório. O simples fato de serem policiais não macula a prova oral de parcialidade, a não ser que haja prova em contrário nesse sentido, o que não ocorreu nos presentes autos.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

"Os policiais militares, como qualquer outra pessoa, não estão impedidos de deporem e seus testemunhos não podem e não devem ser de modo algum, de forma apriorística, considerados suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial". (TJMG. Apelação Criminal nº 1.0349.08.020068-7/001. Relatora Des. MARIA CELESTE PORTO. 5ª Câmara Criminal. Julgado em 27/01/2009).

PROVA - Testemunha - Palavra de policiais quanto aos atos de diligência - Validade - Inexistência, nos autos, de qualquer evidência de má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público - Pedido revisional deferido em parte para reduzir a pena, fixado o regime inicial fechado (Revisão Criminal 99302019068600 - Monte Azul Paulista - Relator Antonio Sérgio Coelho de Oliveira - 16/04/2009 - Voto nº: 7929).

PROVA - Meios - Palavra de policial - Credibilidade - A só condição de policial não o torna suspeito - Depoimento colhido sob compromisso de dizer a verdade, como de qualquer testemunha, que deve ser examinado dentro de todo o conjunto probatório - Seria estranho o Estado selecionar pessoas para integrarem o quadro da Polícia e depois suspeitar delas quando agem no cumprimento do dever, ainda mais se inexistente interesse dos policiais em prejudicar o acusado - Entendimento - Recursos parcialmente providos (Apelação Criminal 99305025506900 - São Miguel Arcanjo 11ª Câmara de Direito Criminal - Relator José Odorico de Oliveira Passos - 17/09/2008 - Voto nº 16.395).

PROVA - Meios - Palavra de policial - Eficácia - Depoimentos de policiais, que efetuaram a prisão em flagrante, harmônicos, coerentes e firmes que ratificam os fatos narrados na denúncia e nenhuma razão tinham para incriminar os acusados, sem motivo plausível ou causa justificável - Credibilidade - Recursos improvidos (Apelação Criminal 11391843000 - Barretos - 11ª Câmara do 6º Grupo as Seção Criminal - Relator Antônio Manssur 30/01/2008 - Voto nº 14.068).

O réu, por sua vez, não nega a propriedade de todo o entorpecente, porém nega que estivesse andando com todo ele na cintura, muito menos balança de precisão, os quais guardou no tal imóvel vazio, de onde havia se mudado há poucos dias. Aduz que

a droga seria para seu uso e que a balança seria para “conferir o peso da droga comprada”.

Insta salientar que não ficou demonstrado nos autos motivo algum para que os policiais quisessem incriminar falsamente o acusado, imputando-lhe o delito de tráfico de drogas e, a considerar o montante de droga reconhecidamente do réu (132,05g), a presença de balança de precisão no mesmo local em que preso, apreensão de R\$ 10,00 (valor comumente conhecido nos meios policiais como sendo valor de venda da porção de maconha) e as notícias de traficância que os policiais já vinham recebendo do réu, o tráfico se configura.

Por sua vez, o acusado não conseguiu trazer aos autos qualquer evidência que faça pairar dúvida sobre as provas acima exploradas.

Passo, assim, à dosimetria da pena.

Vejo que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis, a teor da sua primariedade. Ademais, a análise das circunstâncias judiciais tem por finalidade adequar a quantidade da pena às particularidades que envolvem o fato e o agente, razão pela qual fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Sem agravantes, já que, embora responda a outro processo-crime por tráfico (feito nº 1501202-50.2021.8.26.0438, fls. 183/184 – em processamento) e também por furto (feito nº 1500591-87.2021.8.26.0603, fl. 183 – condenação não definitiva), ainda não há condenação em tal feito. Sem atenuantes, pois, embora confesse a propriedade da droga, aduz, por outro lado, que seria para mero uso.

Sem causa de aumento. Por outro lado, ante a primariedade do acusado e da ausência de indicativos de que ele integre organização criminosa ou se dedique à atividade ilícitas – os outros processos-crime ainda estão em andamento –, vislumbro o cabimento da redução de pena, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porém em 1/3, dada a quantidade de droga (mais de 100g de entorpecente) e apreensão de balança de precisão, perfazendo o montante de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no menor valor.

Pois Bem.

Na sessão do dia 23.6.2016, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que o chamado tráfico privilegiado, no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. A discussão ocorreu no julgamento do Habeas Corpus (HC) 118533, que foi deferido por maioria dos votos:

“O crime de tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda. Por conseguinte, não são exigíveis requisitos mais severos para o livramento condicional (Lei 11.343/2006, art. 44, parágrafo único) e tampouco incide a vedação à progressão de regime (Lei 8.072/1990, art. 2º, § 2º) para os casos em que aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, Lei 11.343/2006. Com base nessa orientação, o Plenário, por maioria, concedeu a ordem de “habeas corpus” para afastar a natureza hedionda de tal delito. No caso, os pacientes foram condenados pela prática de tráfico privilegiado, e a sentença de 1º grau afastara a natureza hedionda do delito. Posteriormente, o STJ entendera caracterizada a hediondez, o que impediria a concessão dos referidos benefícios v. Informativos 791 e 828. O Tribunal superou a jurisprudência que se firmara no sentido da hediondez do tráfico privilegiado. Sublinhou que a previsão legal seria indispensável para qualificar um crime como hediondo ou equiparado. Assim, a partir da leitura dos preceitos legais pertinentes, apenas as modalidades de tráfico de entorpecentes definidas no art. 33, “caput” e § 1º, da Lei 11.343/2006 seriam equiparadas a crimes hediondos. Entendeu que, para alguns delitos e seus autores, ainda que se tratasse de tipos mais gravemente apenados, deveriam ser reservadas algumas alternativas aos

critérios gerais de punição. A legislação alusiva ao tráfico de drogas, por exemplo, prevê a possibilidade de redução da pena, desde que o agente seja primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Essa previsão legal permitiria maior flexibilidade na gestão da política de drogas, pois autorizaria o juiz a avançar sobre a realidade pessoal de cada autor. Além disso, teria inegável importância do ponto de vista das decisões de política criminal.” (Informativo nº 831, STF. HC 118.833/MS, rel Min. Cármen Lúcia, 23.06.2016) (g.n.).

No mesmo sentido, o STJ, em 23.11.2016, por meio de sua 3ª Seção, por unanimidade, acolheu a tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, revisando o entendimento consolidado por ocasião do julgamento do REsp n. 1.329.088/RS - Tema 600, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO. ENTENDIMENTO RECENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC 118.533/MS. REVISÃO DO TEMA ANALISADO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 1.329.088/RS. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO Nº 512 DA SÚMULA DO STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do HC 118.533/MS, firmou entendimento de que apenas as modalidades de tráfico ilícito de drogas definidas no art. 33, caput e § 1º, da Lei nº 11.343/2006 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria “contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa.” (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016). 2. É sabido que os julgamentos proferidos pelo Excelso Pretório em Habeas Corpus, ainda que por seu Órgão Pleno, não têm efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça, é necessária a revisão do tema analisado por este Sodalício sob o rito dos recursos repetitivos (Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 1.329.088/RS - Tema 600). 3. Acolhimento da tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça (Petição nº 11.796 - DF (2016/0288056-2) RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJ 23.11.2016).

Diante disso, como decorrência lógica, e revendo entendimento anterior, não deverá, portanto, incidir no caso o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, na redação dada pela Lei 11.464/07, que estipula como regra o regime fechado para o início do cumprimento da pena. Isso porque, de forma incidental, o Plenário do STF já declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo, afirmando a possibilidade de o condenado por tráfico iniciar o cumprimento da pena em regime menos gravoso que o fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal (HC 111.840/ES, rel. Min.Dias Toffoli, j. 27.06.2012).

Por fim, é cabível, em tráficos privilegiados, A DEPENDER DO QUANTUM DA PENA E DOS DEMAIS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CP, a substituição da sanção corporal por restritiva de direito. Ressalte-se que a Resolução 05/2012 do Senado Federal suspendeu a vedação de conversão em penas restritivas de direitos prevista no art. 44 da Lei de Drogas, declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS.

Em suma, não é possível hoje desconhecer que, notadamente a partir de decisões de seu Tribunal Pleno (HC 97.256/RS Rel. Ayres Britto j. 01.09.2010 m. v.; Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo 663.261/SP Rel. Luiz Fux j. 13.12.2012 m. v.), tal lição tem sido torrencialmente ministrada em julgados unânimes de ambas as Turmas julgadoras do Supremo Tribunal Federal, a quem, inclusive, incumbe o controle máximo da constitucionalidade em nosso País (2ª T HC 124.489/MG Rel. Teori

Zavascki j. 10.03.2015; 1ª T RHC 123.080/BA Rel. Luiz Fux j. 21.10.2014; 1ª T HC 111.015/MS Rel. Luiz Fux j. 21.05.2013; 2ª T HC 115.174/RS Rel. Gilmar Mendes j. 02.04.2013; 1ª T HC 123.622/SP Rel. Luiz Fux j. 23.09.2014; 1ª T HC 120.876/SP Rel. Luiz Fux j. 1ª T HC 120.663/SP Rel. Rosa Weber j. 29.04.2014; 2ª T RHC 120.247/MG Rel. Ricardo Lewandowski j. 25.02.2014; 1ª T HC 116.641/SP Rel. Marco Aurélio j. 25.02.2014; 2ª T HC 118.935/SP Rel. Ricardo Lewandowski j. 26.11.2013; 1ª T HC 115.508/SP Rel. Marco Aurélio j. 05.11.2013; 2ª T HC 115.350/MS Rel. Gilmar Mendes j. 29.10.2013; 2ª T HC 115.153/SP Rel. Gilmar Mendes j. 03.09.2013; 2ª T RHC 111.059/DF Rel. Ricardo Lewandowski j. 05.06.2012; 2ª T HC 111.247/MG Rel. Ricardo Lewandowski j. 27.03.2012).

Não diverso tem sido também o entendimento unânime adotado pelas duas Turmas de competência criminal do Superior Tribunal de Justiça (5ª T HC 298.792/SP Rel. Newton Trisotto j. 24.03.2015; 6ª T HC 213.412/ES Rel. Nefi Cordeiro j. 19.03.2015; 6ª T HC 187.874/MG Rel. Nefi Cordeiro j. 19.03.2015; 5ª T HC 308.380/SP Rel. Leopoldo de Arruda Raposo j. 05.03.2015; 5ª T HC 299.780/SP Rel. Newton Trisotto j. 03.03.2015; 6ª T HC 309.663/SP Rel. Nefi Cordeiro j. 03.03.2015; 5ª T HC 291.136/SP Rel. Felix Fischer j. 24.02.2015; 5ª T HC 307.913/SP Rel. Felix Fischer j. 24.02.2015; 5ª T HC 306.352/SP Rel. Felix Fischer j. 12.02.2015; 6ª T HC 307.489/SP Rel. Ericson Marinho j. 12.02.2015; 5ª T HC 301.120/SP Rel. Newton Trisotto j. 10.02.2015; 5ª T HC 292.602/SP Rel. Newton Trisotto j. 10.02.2015; 5ª T HC 297.405/SP Rel. Newton Trisotto j. 10.02.2015; 6ª T HC 310.798/SP Rel. Maria Thereza de Assis Moura j. 03.02.2015; 6ª T AgRg no AREsp 436.420/DF Rel. Sebastião Reis Júnior j. 03.02.2015; 5ª T HC 304.439/SP Rel. Felix Fischer j. 03.02.2015). ASSIM, NO CASO EM ANÁLISE, ressalto que a pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicial aberto, consoante art. 33º, § 2º, "c" do Código Penal (não reincidente e pena inferior a quatro anos).

Presentes os requisitos legais, substituindo somente a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena corporal, e prestação pecuniária, no importe de 2 (dois) salários mínimos, a serem destinado ao Fundo Municipal da Infância e Juventude, nos termos do § 2º, segunda parte, do art. 44, do CP.

Assim, a pena perfaz o montante de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no menor valor, substituída a pena corporal por PRD, nos termos retro.

III - Do Dispositivo

Ante ao exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu HIGOR GABRIEL HERRERO como incurso no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, devendo cumprir a pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa,, no menor valor, substituída a pena corporal por PRD, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena corporal, e prestação pecuniária, no importe de 2 (dois) salários mínimos a serem destinados ao Fundo Municipal da Infância e Juventude, nos termos do § 2º, segunda parte, do art. 44, do CP.

A considerar a natureza da pena imposta, bem como a primariedade técnica, CONCEDO-LHE o direito de recorrer em liberdade.

Custas na Forma da lei, visto que a ré é beneficiária da Lei nº. 1.060/50.

Deve a droga apreendida ser destruída se ainda não foi. Declaro o perdimento do numerário apreendido, vez que não foi comprovada sua origem lícita, bem como do objeto apreendido nos autos (celular), encaminhando-o para destruição.

P.I.C.

Penápolis, 11 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA